



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. מתי ולטר
טובה ולטר
ע"י ב"כ עוה"ד רפאל שויביץ
משדרות ירושלים 29 רמת גן

2. יעקב רוט
אריקה רוט
שניהם מרחוב מל"ל 11 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים:

1. אהרון ישראלי
רויטל ישראלי
2. אסף טרצינר
הדר טרצינר
הנתבעים ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי גלוסקה
מרחוב אבא הלל 15 רמת גן

פסק דין

הסכסוך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב מל"ל 11 רמת גן הבנוי על חלקה 136 בגוש 6159 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי. בבית 6 דירות ב- 3 קומות.

התובעים טוענים כי הנתבעים קיבלו היתר לבנית 2 ממ"דים המורכבים מ- 24 מ"ר שטח לממ"ד ועוד 11.94 מ"ר שטחים עיקריים ולסגירת מרפסות. ביום 15.04.12 הנתבעים החלו בביצוע העבודות. דא עקא, בידי הנתבעים אין הסכמה נדרשת של בעלי הדירות לביצוע העבודה. בפועל, רוב בעלי הדירות מתנגד אקטיבית לבניה. לטענת התובעים, הבניה המבוקשת, בחלל בקומת הקרקע, איננה לוקחת בחשבון את זכויות בעלי הדירות האחרים, איננה מאפשרת להם לבנות מעל הממ"דים המוצעים ואיננה כוללת תוכנית מערכתית לבית. משמעות הבניה היא כי לכשיבקשו בעלי הדירות האחרים לבנות ממ"דים יהיה עליהם לעשות כן ממפלס הקרקע.

בנוסף לאמור לעיל הרי שהנתבעים גם השתלטו על החצר המשותפת והפכו אותה לגינה פרטית ומגודרת אשר הכניסה אליה רק מדירותיהם. במסגרת ההיתר הם גם מבקשים להצר עוד את שער המעבר לגינה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור כל האמור לעיל טוענים התובעים כי יש ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים להוציא לפועל את הבניה המתוכננת. כן נתבקש צו המורה לנתבעים להסיר את הגדרות ולאפשר גישה חופשית לחצר הבית.

הנתבעים טוענים כי התובענה מהווה שימוש לרעה בזכות של התובעים. הנתבעים ניסו במשך שנים לקדם פרוייקט כלשהו בבית לשיפוצו וחיזוקו. אולם, כל הצעותיהם נדחו. גם כנגד הבקשה להיתר בניה דנן הוגשה התנגדות וזו נדחתה. התובעים הגישו ערר על דחייה זו שנדחה גם הוא ומאז, משך חודשים רבים, לא נקטו התובעים כל צעד משפטי, אלא רק לאחר תחילת ביצוע העבודות על ידי הנתבעים. לטענת הנתבעים לא תגרם לתובעים כל פגיעה כתוצאה מהיתר הבניה וממילא לא ניתן להכין תוכנית מערכתית בהעדר שיתוף פעולה של התובעים.

הנתבעים טוענים כי דין התביעה להידחות בשל היות התנגדות התובעים לבניה שלא בתום לב, בגין היות התנגדותם שימוש לרעה בזכות ולאור היות התביעה מנוגדת למדיניות המחוקק לחיזוק ושיפוץ בתים.

אזכיר כי ראשיתה של תובענה זו בבקשה למתן סעד זמני שנתקבלה בהחלטתי מיום 21.05.12.

דיון

מסגרת הדיון המשפטי בהליך דנן עניינה בסימן 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הידוע גם כ"תיקון 18" לחוק.

הכלל הקבוע בחוק המקרקעין הוא כי על מנת לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף יש צורך בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית משותף.

סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

כך גם קובע סעיף 12(ב) לתקנון המצוי כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה לא תהיה לה תוקף כלפיו, אלא אם אותו בעל דירה הסכים לה. המשמעות של הסעיף האמור, גם היא, כי נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות כדי לשנות זכויות קנייניות של בעלי הדירות בבית.

תיקון 18 לחוק המקרקעין מהווה חריג חקיקתי לכלל זה.

סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע כלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

ההסכמה של בעלי הדירות (כולם או 3/4 מהם או 60% מהם, בהתאם לנסיבות כאמור) לכל גריעה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת (רע"א 259/99 חב' פליצי' ראובן בע"מ נ' סופיוב פ"ד נה(3) 385, 402 ולסקירת הפסיקה בנדון גם ע"א (מחוזי חי') 1677/05 כרמל נ' ינקוביצי (פורסם בנבו)).

הסכמה כנ"ל יכולה להינתן גם בעל פה. אולם, עליה להיות מוכחת בראיות מספיקות (עא (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רחזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא(1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלס נ' אידלברג (פורסם בנבו)).

בדומה לתיקון 18, בנסיבות בהן חל חוק המקרקעין (חיזוק בתים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק") קובע סעיף 4 חריג חקיקתי נוסף לפיו:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הרחבת דירה, טעון החלטה מראש של מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות בבית המשותף, בדבר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם הצמדתם לאותה דירה וכן בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לשם ביצוע עבודה"

יוצא, אם כן, כי המחוקק התיר בחקיקה ספציפית פגיעה מסוימת בזכויות הקניין של בעלי דירות בבית משותף - חלף הסכמה של כל בעלי הדירות להצמדה של חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה פלונית, קבע המחוקק, כאמור, רף נמוך יותר של הסכמת 3/4 מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה או הסכמה של 60% מבעלי הדירות כדי להכשיר בניית ממ"ד או ממ"ק. בנסיבות בהן חל חוק החיזוק נדרשת הסכמה של 60% לצורך אישור עבודה שמטרתה הרחבת דירה.

במקרה דנן אין מחלוקת כי הנתבעים לא קיבלו הסכמה נדרשת של רוב בעלי דירות בבית בהתאם להוראות תיקון 18 לחוק המקרקעין ו/או בהתאם להוראות חוק החיזוק – התובעים הינם בעלים של 2 דירות בבית להם צמודים 160/432 חלקים מן הרכוש המשותף. הנתבעים מודים כי אין בידם הסכמה פוזיטיבית של בעלת דירה נוספת בבית – גב' חוה בק, לדירתה צמודים 78/432 חלקים מן הרכוש המשותף בבית (עמוד 4 שורות 15-16). את האמור גם מאשרת הגב' ישראל בעדותה – "היו לי שיחות עם מר רוט. ש.ת. הוא לא אמר לי אף פעם שהוא מסכים לבניית ממ"ד ידעתי בוודאות שהוא מתנגד. ש.ת. העמדה של מתי גם הייתה ברורה. ש.ת. ניסינו להשיג הסכמה מהגב' בק הם לא היו בעד וגם לא שללו. ש.ת. אמרתי להם שמאוד חשוב לי לקבל את ההסכמה אבל אמרו לי שהם לא יסכימו בגלל הדיירים" (עמוד 13 שורות 25-29). גם מר טרצינר מאשר, למעשה, את האמור (עמוד 15 שורות 3-17).

לאור האמור, הרי שבידי הנתבעים, לכל היותר, הסכמה של 50% מבעלי הדירות בבית לדירותיהם צמודים 194/432 חלקים בלבד מן הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות אלו, אף אם המדובר בבנייה של ממ"ד בלבד מכח הוראות סעיף 71ב(א) סיפא לחוק המקרקעין הרי שאין בידי הנתבעים את ההסכמה הנדרשת של בעלי הדירות בבית לביצוע העבודות המבוקשות על ידם לבניית ממ"ד (60% מבעלי הדירות).

במאמר מוסגר אעיר כי, למעשה, אין מחלוקת כי בנוסף לממ"ד מבוקש לבצע בניה על חשבון שטחים נוספים, כפי שגם מאשר המומחה מטעם הנתבעים בעדותו (עמוד 10 שורות 23-24), לרבות סגירת מרפסות (שבבירור אינן נכללות בגדר ממ"ד). ברי כי אין בידי הנתבעים הסכמה של הרוב הגדול יותר הנדרש לצורך ביצוע עבודות הרחבה שאינן בגדר ממ"ד בהתאם להוראות סעיף 71ב(א) רישא (3/4 מבעלי הדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף).

גם הסכמה נדרשת על פי סעיף 4 לחוק החיזוק (60% מבעלי הדירות) אין בידי הנתבעים.

לפני סיום פרק זה עוד שתי הערות.

ראשית, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי בידם הסכמה לבניה המבוקשת של בעלי דירה נוספת (תת חלקה 6) – ה"ה ספורמס. למעט טענת הנתבעים כי בידם חתימת "פרידה ספורטס" (עמוד 1 שורה 27 ועמוד 15 שורה 6) הרי שלא הובאה כל ראיה לתמיכה בטענה זו – ה"ה ספורמס לא זומנו למתן עדות בהליך שבפני. אפילו מסמך הסכמה בחתימתם לא הוצג בפני. הנטל להוכחת קיומן של הסכמות מוטל על המבקשים לבצע את הבניה, קרי, הנתבעים, ולא עלה בידם להוכיח הסכמת ה"ה ספורמס. ויודגש, הנתבעים בסיכומיהם טוענים כי לא הוכחה התנגדות של חלק מבעלי הדירות בבית. טעות משפטית נפלה בידם בהקשר זה - הנטל הוא על מבקש הבניה להוכיח כי בידו הסכמות פוזיטיביות ואין כל נטל על המסרבים לבניה להוכיח "התנגדות".

גם בנוגע להסכמת הגב' בק יש מקום להזכיר כי בדיון המקדמי הצהיר ב"כ הנתבעים כי "ראשית אני מבקש להתנצל כי איתרנו את הגב' חווה בק. לא רק שהיא אינה מתנגדת, יש בעיה משפחתית שהם צריכים לפתור ולא מן הנמנע שתהיה הסכמה" (עמוד 1 שורות 22-23). לא רק שלא עלה בידי הנתבעים להציג הסכמה של הגב' בק, לא רק שלא עלה בידם להביאה לעדות בפני, הרי שהם גם התנגדו לשמיעת עדות בנותיה של הגב' בק בפתח ישיבת ההוכחות מיום 31.10.12. כל אלו מבססים, גם הם, כי אין בידם של הנתבעים כל הסכמה של הגב' בק לבניה המבוקשת על ידם.

ההלכה קובעת בהקשר האמור כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"ל לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רונברג ואח' פ"ד מז (2) 606). הנתבעים חדלו מלהביא ראיות זמינות (הן בנוגע לגב' בק והן בנוגע לה"ה ספורמס) וניתן לפיכך להסיק מסקנה ראייתית כי עדותם של אלו היתה פועלת לרעת הנתבעים, קרי, לא ניתנה הסכמה של הנ"ל לבניה המבוקשת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי הבניה המבוקשת על ידם נכללת בגדרו של חוק החיזוק – סעיף 2 לחוק החיזוק קובע כי: "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

דא עקא, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי נתקבל בידם היתר לפי חוק התכנון והבניה על פי תמ"א 38 – היתר הבניה (נספח 7/1 לתצהירי הנתבעים) אינו מאזכר כלל את תמ"א 38 ובודאי שלא מצוין כי הוא הוצא מכוחה. כך גם ועדת הערר איננה מתייחסת לקשר שבין הבקשה להיתר לבין תמ"א 38 (חלק מנספח 3/1 לתצהירי הנתבעים). שני ההליכים מתייחסים לבקשה למתן היתר "לתוספת 2 ממ"דים" ללא כל קשר לתמ"א 38. גם המומחה מטעם הנתבעים אינו יכול לאשר כי ההיתר הוצא מכוח תמ"א 38 – "לא כתוב בהיתר כאן שזה מכוח תמ"א 38. ש.ת. אני לא אגיד שטעיתי משום שהתייחסתי בחוות דעתי למספר שאלות שנשאלו הוזמנתי והתבקשתי לענות אף אחד לא שאל אותי ולכן גם לא בדקתי ולא זכור לי שרשמתי ובדקתי את נושא הרישוי אני רק ציינתי שהתמ"א מאפשרת תוספת של 25 מ"ר לדירה. לא נכנסתי לנושא הרישוי. ש.ת. אני לא בדקתי את נושא הרישוי. זה שלא רשום תמ"א במסמך זה ברור" (עמוד 10 שורות 26-30). משכך, לא עלה בידי הנתבעים, המבקשים להסתמך על חוק החיזוק, להוכיח תחולתו במקרה דנן.

די באמור לעיל כדי להביא לקבלת התביעה.

אולם, הנתבעים, אשר היו מודעים לכך כי אין בידם את הרוב הנדרש על פי הדין לביצוע הבניה, ביססו את הגנתם על הטענה כי סירובם של התובעים לאפשר הבניה הינו בחוסר תום לב ותוך שימוש לרעה בזכותם הקניינית. לטענתם, יש באלו כדי להתגבר על העדר רוב נדרש לביצוע העבודות המבוקשות. עוד ביקשו להתבסס על מדיניות המחוקק בנושא חיזוק בתים.

אין בידי לקבל טענה זו של הנתבעים, לא מן הבחינה המשפטית ולא מן הבחינה העובדתית.

דעתי היא כי רף ההסכמה הנמוך אשר נקבע על ידי המחוקק בתיקון 18 ובחוק החיזוק הינו רף מינימלי שבהעדרו לא ניתן לאשר ביצוע עבודה ברכוש המשותף. כאמור לעיל, בתיקון 18 ובחוק החיזוק קבע המחוקק רף הסכמה נמוך מזה הנדרש על פי דיני המקרקעין הרגילים, זאת תוך פגיעה מסויימת בזכות קניין של בעלי דירות בבתים משותפים. זכות הקניין מוכרת כיום גם זכות יסוד בהתאם להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולפיכך יש לפרש את תיקון 18 ואת חוק החיזוק פירוש דווקני וכדי להיכנס לתחולתם יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו בהם, ככתבם וכלשונם. לדעתי, אין למפקח על רישום מקרקעין שיקול דעת לסטות מהוראות חוק המקרקעין וחוק החיזוק במקרה זה ומי שאינו עומד בתנאי המינימום שנקבעו בחוקים הנ"ל, אינו יכול לחסות בצילם.

בניגוד לטענת הנתבעים בסיכומיהם, כך גם מנחה אותי ערכאת הערעור בנוגע לתיקון 18 – "כבעלי זכות קניין, שהיא זכות יסוד, רשאים המשיבים לנהוג ברכושם כרצונם, ואין עליהם ליתן טעם מדוע הם מסרבים לגרוע מזכות זו, רק משום שהמערער מבקש לבנות על חשבונם ולספח לעצמו חלק מהמקרקעין שלהם" ובהמשך "החוק קבע אמות מידה להסכמה, בהן כבר איזן את האינטרסים של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כל הצדדים. מאחר שהמדובר בפגיעה בזכויות קנייניות, אשר החוק למעשה גורע מהן, יש לקיימו בדווקנות" (עש"א (מחוזי ת"א) 2016/09 יצחק זלצר נ' מאיר הולצמן (פורסם בנבו)).

אומנם, בדעת רוב קבע הרכב השופטים בע"א (מחוזי חיפה) 835/08 נטלה צבי נ' עטרה פרי ואח' (פורסם בנבו) כי אין בידי בעל דירה לבוא לבית המשפט ולהתנגד לבניה מבוקשת מבלי להעלות נימוקים להתנגדותו ויכול להתנגדות שכזו תהווה "עמידה על קוצו של יוד במימושה של הזכות" והמפקח יוכל להתערב בה.

אולם, בדיון מאוחר יותר בעש"א 17181-05-11 אברהם נ' פדאל (טרם פורסם) הבהיר בית המשפט המחוזי (בהרכב בו ישבו שניים מבין השופטים שישבו בדין בפרשת נטלה צבי הנ"ל) כי סמכות המפקח לפסול התנגדות הינה רק כאשר התנגדות זו נעשית, למעשה, ללא כל הנמקה. בפסק הדין נקבע והובהר, בנסיבות בהן נתקבל ערעור על פסק דין בו פסלה המפקחת בנצרת את טיעוני ההתנגדות של המערערים, כי "אין בית המשפט צריך לשים עצמו במקומם של בעלי הדין" ובהמשך "לאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר".

כך גם נקבע על ידי אותה הערכאה בדעת רוב בעש"א (מחוזי חיפה) 13877-07-09 אילן קסרי נ' שאחב שלומוב (פורסם בנבו): "זאת ועוד, נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש משותף הינה כי לאף אחד מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף. תפיסה של הרכוש המשותף לשימוש ייחודי ובנייה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים, ולמצער, הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969... דייר המתחיל לבנות ללא פניה לשאר בעלי הבית פועל בחוסר תום לב. גם אם לא מושגת ההסכמה, משיקולים הנראים בעיני המבקש כפסולים, אל לו לעשות דין לעצמו ועליו לנקוט בהליך מתאים בבית המשפט או בפני המפקחת כדי לכפות את ההסכמה...מכל מקום, הסתמכות על העדר תגובה בנסיבות שכאלו אינה התנהגות בתום לב. זאת ועוד, לגישת חברי על המתנגד לבנייה לשכנע כי עומדים לו נימוקים ענייניים וסבירים על פי מבחן אובייקטיבי. איני יודע מהם אותם נימוקים שיעמדו במבחן האובייקטיבי, ודומני כי התנגדות של אדם לעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף תהא בדרך כלל התנגדות עניינית. אין כל מקום לכפות על אדם לוותר על קניינו רק בשל רצון של שכן לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף. גם עמידתו של דייר על קבלת טובת הנאה כלשהי כתנאי למתן הסכמתו לוותר על זכויותיו, אפילו טובת הנאה כספית, אינה מהווה בהכרח חוסר תום לב. גם התנגדות בשל החשש לירידת ערך הדירה של המתנגד אינה חסרת תום לב. אוסיף, כי ראוי שבית המשפט יזהר פן ישים עצמו במקומם של בעלי הדין. עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה ברכוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים" (ההדגשה שלי, א.ס.).

יש גם לזכור את עמדתו של השופט כהן בפרשת נטלה צבי הנ"ל (אשר ישב גם בהרכב בפרשת פדאל הנ"ל): "במשטר שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, נתן המחוקק את הכוח בידי רוב בעלי הדירות "להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה". במילים אחרות, הרכוש המשותף מוגן ב"הגנה קניינית", ולצורך הסרת ההגנה, דרוש רוב מסויים שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. הפועל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

היוצא מכך הוא, שמי שאינו מצליח לגייס את הרוב הדרוש, כמו המערערת שלפנינו, לא יוכל לקבל חלק מסויים מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו... הנימוקים המשמשים את המשיבים, להצדקת התנגדותם לתוכניתה של המערערת להרחבת דירתה על חשבון הרכוש המשותף, אינם טובים פחות מהנימוקים המשמשים את המערערת להצדקת תוכניתה להרחבת הרכוש המשותף, והנני סבור, שלא ניתן לאיין את נימוקיהם של המשיבים תוך עשיית שימוש בסעיף 14 לחוק המקרקעין. זכותם של המשיבים להתנגד מעוגנת במשטר הזכויות שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ומשעה שהמערערת לא הצליחה להשיג את הרוב הדרוש למימוש תוכניתה, לא ניתן לכפות על המשיבים את תוכניתה, שכן זכויותיהם ברכוש המשותף קיבלו מהמחוקק הגנה קניינית, שלא "פוצחה" על ידי המערערת ברוב הדרוש... אם חפצה המערערת לפתור את בעייתה, ולממש את תוכניתה להרחבת דירתה על חשבון הרכוש המשותף, הפתרון מצוי מחוץ לכתלי בית המשפט. על מנת לקבל את הרוב הדרוש לשם מימוש תוכניתה, על המערערת לנהל מו"מ עם יתר בעלי הרכוש המשותף ולנסות לקנות את הסכמתם... והיה אם לא יגיעו הצדדים להסכמה על המחיר, דבר המחוקק הוא שיהיה - בהעדר הרוב הדרוש, לא תוכל המערערת להרחיב את דירתה" (ההדגשות שלי, א.ס.).

בהקשר דנן התובעים העלו נימוקים להתנגדותם לבניה המבוקשת - כך מעידה למשל הגב' ולטר "לא בצורה הזו של בנייה של שני דיירים ממ"ד לעצמם תוך חסימת המקלט שלנו תוך גניבה של שטח הבנייה שלנו בחצר וכל זה אחרי שהם לקחו מאחורה את החצר ועשו אותה כדירות גן ששם עושים על האש ורעש שתלו צמחייה שלא מאפשרת לנו לעבור הם ביקשו סגירת מרפסות זה היה לפני כמה שנים הם עשו זאת בלי רשות ועכשיו הם רוצים לגיטימציה על זה" (עמוד 6 שורות 25-29) ובהמשך "לא יהיה מקובל עליי גם אם לא ייפגעו זכויות הבנייה שלי הם לקחו את כל החצר אין לי איפה לבנות ממ"ד או להוריד כביסה או להחליף גז הכול חסום הם לקחו את כל החצר מקדימה ומאחורה אני מתנגדת בכל מצב וזה ידוע לכולם" (עמוד 7 שורות 12-14). מר בק מוסיף עוד בעדותו "לא היה דיבור על זה אבל אני מסכים לבנות ממ"ד מאחורינו למרות שיש מקלט על מטר 75 ס"מ לפני הדירה אבל אם הם רוצים לבנות ממ"ד לבריאות מאחורנית. אני רוצה גינה מקדימה כמו בכל הרחוב. הרסו הכול בשיטתיות" (עמוד 8 שורות 1-3) ובהמשך "אני לא מסכים לבנייה הזאת של הממ"ד במיקום שהם רוצים היום. ש.ת. אם יבנו ממ"ד לכולם מלמטה עד למעלה מאחור אני לא מתנגד" (עמוד 8 שורות 13-14).

כלומר, אף לפי הגישה המרחיבה שבפרשת נטלה צבי עליה מסתמכים הנתבעים (לפני שזו הובהרה וצומצמה בפרשת פדאל הנ"ל ובפרשת קסרי), הרי שדי בנימוקים טובים אלו, שבדאי אינם בגדר נימוקים "פסולים", כדי לשלול מהנתבעים לבצע את הבניה המבוקשת בהעדר רוב נדרש בהתאם להוראות הדין.

אף אם נבחן את תום הלב של הצדדים בתיק זה, הרי שאין בבחינה זו כדי לסייע לנתבעים.

אומנם, בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737 נפסק כי ניתן להחיל נורמות ממערכות היחסים שבין בעלים במקרקעין משותפים גם על יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף. כך גם פוסק כב' השופט ח. כהן פסק בע"א 782/70 דדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523. כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550, מחיל את עיקרון "תום לב" על יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, כאמור לעיל, תיקון 18 וחוק החיזוק מתירים פגיעה בזכויות קניין בנסיבות מסוימות בלבד. משכך, יש לדקדק בקבלת ההסכמות הנדרשות על פי הדין וממילא לא ניתן לאשר בניה בהסכמה פחותה מההסכמה הנדרשת בחוק. די בכך שמעולם לא היתה בידי הנתבעים הסכמה מספיקה של בעלי דירות כדי לקבוע שהתנגדות התובעים דנן לבניה נעשתה כדין ואין בה דופי.

הנתבעים מבקשים להסתמך על פסקי הדין בפרשת רוון ביזנס המאוזכרים בסיכומיהם. דא עקא, אין בפסקי דין אלו כדי לסייע. ההפך הוא הנכון. מעבר לעובדה כי שם המדובר בבחינת הוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין (שאינו קשור לתיקון 18 לחוק), הרי ששם בידי התובעים היה הרוב הדרוש בהתאם להוראות הדין לביצוע העבודות המתוכננות. שם דווקא נדחתה טענת המיעוט לביצוע עבודות שיקום בדרך המוצעת על ידו, בהעדר הסכמה ברוב הנדרש של בעלי הדירות בבית.

כך גם אין בפסקי הדין בפרשת קלצ'וק אשר אוזכרו בסיכומי הנתבעים את אשר הם קוראים בהם. בחינת תום הלב המדוברת שם היא של החלטת רוב בעלי הדירות (על פי המניין הנדרש בדין), המבקשת לכפות על המיעוט לבצע עבודות חיזוק. בעניינו מצב הדברים הוא הפוך – המיעוט, שאין בידו הסכמת רוב כדין, מבקש לכפות בניה על בעלי הדירות האחרים. לכאורה, אם נחיל את פרשת קלצ'וק לענייננו, הרי שאת תום ליבם של הנתבעים יש לבחון.

על אף האמור לעיל מוצא אני לנכון להבהיר כי בנסיבות דנן, בחינת תום ליבם של בעלי הדין מלמדת כי דווקא הנתבעים הם אלו אשר פעלו בחוסר תום לב תוך שקילת האינטרסים האישיים שלהם והתעלמות, אפשר לומר מופגנת, מטענותיהם וזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים בבית.

הנתבעים, בעיקר הנתבעים 1, מתעקשים על בניית הממ"ד בחזית הבית כפי שמפורט בהיתר הבניה. מאידך, התובעים אינם מתנגדים לבניית ממ"דים כשלעצמם בבית. לטענתם, הדרך הראויה לבניית ממ"דים בבית הינה בחזית העורפית באופן כזה שגם כל בעלי הדירות האחרים יוכלו לבנות ממ"ד לדירתם. למעשה, הנתבעים 2 אינם מתנגדים לבניית הממ"דים בחזית האחורית, כפי שעלה בדיון בפני (עמוד 16 שורות 6-8). אף על פי כן, גם הם ממשיכים בניהול ההליך חלף הגעה להסכמות עם התובעים ובעלי הדירות האחרים. דווקא "התעקשות" הנתבעים בהליך על בניה בחזית הבית היא זו המהווה התנהגות בחוסר תום לב.

הגב' ישראלי מצדיקה את התנהלותה בכך שלא ניתן לטענתה לבנות ממ"ד בחלק האחורי של הבית (עמוד 12 שורות 20-22) היא גם מכחישה כאילו טענת התובעים בפני ועדת הערר היתה כי לא מכינים תוכנית מערכתית לבניית ממ"דים בבית (עמוד 13 שורה 10). עדות זו איננה מקובלת עלי ונסתרה על פי עדויות הנתבעים עצמם.

ראשית, עדות זו עומדת בסתירה לעדות המומחה מטעם הנתבעים אשר אישר בעדותו כי ניתן לבנות פיר ממ"דים לאורך כל הבניין וזה יוכל לשמש את כל בעלי הדירות, כולל הדירות בקומה הראשונה (עמוד 11 שורות 9-13). הגב' ישראלי איננה מומחית לדבר ובכל הקשור לאפשרות הבניה בחזית העורפית המדובר בסוגיה שבמומחיות כך שממילא אין לעדותה משקל כלשהו. היא גם לא הביאה לעדות את כל אותם יזמים המוזכרים בעדותה הנ"ל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, עדותה עומדת בניגוד לעדותו של מר טרצינר לפיה "אני מאשר שהייתה טענה למה נותנים לנו לבנות את הממדים ולא פתרון לכולם" (עמוד 15 שורה 19).

שלישית, אזכיר כי הגב' ישראלי גם "שכחה" לציין בתצהירה, בחוסר תום לב, כי בדיונים המוקדמים בין בעלי הדירות הועלתה הצעה לבניית ממ"דים לכל בעלי הדירות (עמוד 13 שורה 7).

זאת ועוד. מעדותו של המומחה עולה כי משמעות בניית הממ"דים בחזית כמבוקש על ידי הנתבעים הינה כי הם יוכלו להנות מהרחבה נוספת לדירתם, למעשה, על חשבון ובמימון בעלי הדירות האחרים בבית – אם ההיתר הזה יישאר כמו שהוא הם ישתמשו בפיר של השלוש קירות ממ"ד כחדר לכל דבר ועניין והדיירים בקומה הראשונה והשלישית השתמשו בזה כממ"ד. ש.ת יהיה להם ממ"ד מקדימה וחדר מחוזק מאחורה. פיקוד העורף מחייב בתמ"א ירידה של שני קירות ליסודות להבדיל מבנייה חדשה ששם מחויבים ל-70%. אם יתכננו פיר בעורף שני קירות יהיו מבטון שאר הקירות יהיו מבלוק או לא יהיו בכלל וזה ישמש את הקומות העליונות כממ"ד. ש.ת אפשר להמשיך את קיר היציקה שישמש כממ"ד" (עמוד 11 שורות 20-13).

לחילופין, המשמעות של בניית ממ"ד כמבוקש על ידי התובעים היא כי הגינה העורפית תישאר במצבה, כפי שהוא, כאשר מדירותיהם גישה ישירה לגינה זו (ראה מוצגים ת/1 ו-ת/2).

כלומר, בבניה המתוכננת מבקשים הנתבעים "להנות" מכל העולמות – מחד להרחיב את דירתם לרבות הוספת ממ"ד ומאידך להותיר אפשרות להרחבה נוספת של דירתם על חשבון בעלי הדירות האחרים בבית או הותרת גינה פתוחה להם גישה ישירה אליה מדירותיהם.

את כל זאת מבקשים הנתבעים "להשיג" מהרכוש המשותף, ללא קבלת הסכמה של בעלי הדירות ותוך התעלמות מזכויותיהם והנזקים הצפויים להם - אלו יצטרכו לשאת במימון נוסף (עבור הנמכת היסודות ב- 3 קירות עד למפלס הקרקע) אם יחפצו לבנות ממ"ד לדירותיהם, חזית הבית תצטמצם עקב הרחבת דירות הנתבעים אליה ובכלל האמור מבטלת הבניה, למעשה, את כל שטח הגינה בחזית הבית וגם המקלט הקיים עשוי להיפגע עקב הבניה המבוקשת (ר' עדות הגב' ולטר בעמוד 6 שורה 2 וכן העובדה כי המומחה מטעם הנתבעים לא בדק נושא זה ולא יכול היה להעיד בעניינו – עמוד 11 שורות 6-3).

זאת ועוד. מעיון בתשריט היתר הבניה (נספח ד' לתצהיר ולטר וחלק מחוו"ד וינלס) עולה כי הבניה המתוכננת מגיעה עד לקצה גבול החלקה ובכך חוסמת, למעשה, מעבר מתוך שטח החלקה לצידו של הבית ולחלקו האחורי. על פי תשריט ההיתר, דרך המעבר לגינה ההיקפית תהיה דרך שער בגדר החיצונית (המובילה לגינה המזרחית). על פי תשריט ההיתר, מעבר בעלי הדירות לגינה, לבלוני הגז ולפחי האשפה מתוך שטח החלקה יחסם לחלוטין ועליהם יהיה לצאת אל הרחוב ורק משם יוכלו לשוב ולחזור לגינה ולמתקנים המשותפים הנ"ל. כל אלו מהווים גם פגיעה מהותית כשלעצמה, אשר איננה יכולה להצדיק אישור הבניה בהעדר הסכמה של רוב נדרש של בעלי הדירות בהתאם להוראות הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ואדגיש, לא ניתן היה שלא להתרשם מעדותה של הגב' ישראלי כי היא פועלת תוך התחשבות בטובתה האישית בלבד - משלא עלה בידה לשכנע את בעלי הדירות להסכים לבנייה בבית על פי מתווים שהוצעו על ידה (תוך התעלמות מוחלטת, אפילו כתצהירה, מהצעות בעלי הדירות האחרים למציאת פתרון כולל לסוגיית הממ"דים), היא החליטה לפעול באופן חד צדדי, תוך התחשבות בעצמה בלבד וכלשונה - "הכלל לא רוצה לדאוג לכלל אז נשאר לנו לדאוג לעצמנו יש לנו שני ילדים לא השארנו לי ברירה" (עמוד 13 שורה 5) ובהמשך "יש בן אדם שלא דואג לעצמו השכנים שלי גם דואגים לעצמם" (עמוד 13 שורה 22).

האמור גם עולה מעדות מר טרצינר - "בשנת 2010 לפני שבכלל הגשנו ועשינו משהו בקשר לממדים שלנו ההצעות הראשונות היו למה שנקרא תמ"א 38 שזה מוסיפים שני קומות ומוסיפים לכל הדיירים ממ"ד מאחר שבישיבות שהיינו אצל הקבלנים הם אמרו שתהליך כזה לוקח כמו שנתיים וחצי השכנים אמרו שהם לא רוצים לחיות באתר בנייה שנתיים וחצי אז פנינו להצעות של תמ"א 38 ב' ולאחר מכן התחלנו באישורים לבנות ממ"ד לטובתנו ולא לטובת הכלל" (עמוד 14 שורה 27 עד עמוד 25 שורה 2). כלומר, הנתבעים יזמו בניה על פי רצונם, ומשלא עלה בידם לאשרה ברוב הנדרש פעלו באופן חד צדדי וללא הסכמת בעלי הדירות. התנהלות הנתבעים, כפי שבאה לידי ביטוי גם בעדויות אלו, חסרת תום לב.

מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי לו היו פועלים הנתבעים בתום לב מול בעלי הדירות האחרים לבניית פיר ממ"דים משותף בחזית האחורית, הרי שהיה מצוי לכך הרוב הנדרש בין בעלי הדירות בבית ומן הראיות המקצועיות שהוצגו, הדבר גם אפשרי מבחינה תכנונית. לו פעלו כך יכולים היו, גם הנתבעים, לקבל את "ההגנה" ו"הביטחון" שבהם הם חפצים. התעקשותם מלמדת כי לא זוהי מטרתם האמיתית בבנייה המבוקשת, אלא ניצול מקסימלי, לטובתם הפרטית, של הרכוש המשותף בבית. הנתבעים אינם יכולים לחסות תחת ססמאות של "הצלת חיים", "רעידות אדמה" "מיגון של הילדים", "מדיניות מחוקק" וכיוצ"ב, כאשר הם עצמם מכשילים את אפשרות בניית הממ"דים בבית לכל הדירות, לרבות לדירותיהם, בדרך שיש בה גם לשמור על זכותם הקניינית של כל בעלי הדירות בבית. ויזכר, גם זכות הקניין הינה זכות יסוד במשפטנו ועולמנו.

משכך, בכל מקרה, אין המדובר במקרה נדיר וחריג המצדיק שלא להיעתר לתביעה שמטרתה להגן על זכות קניין (ר' רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח' פד"י נ"ה(1) 199 והעקרונות שנקבעו שם בעניין זה).

ראוי לאזכר בהקשר זה גם את דבריו של כבוד הנשיא אולשן בע"א 281/61 משה שלוסר נ. יעקב כץ, פד"י ט"ו(3) 239 "אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כלשהי מרכושו של הזולת רק מפני שנח לו הדבר, או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא - אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה אליו מצד בני אדם. אין לזהות שיקולים שביושר במשמעות המשפטית, דבר התלוי ברצונו הטוב של הזולת, אין לכפות עליו "רצון טוב" זה על ידי החלת שיקולים שביושר. עוד לא שמענו על הלכה מעין זו" (ההדגשה שלי, א.ס.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

וכך גם במקרה דנן - גם אם הנתבעים חפצים בהרחבת דירתם, גם אם הם חפצים בהתקנת ממ"ד חלף השימוש במקלט/מחסה הקיים בבניין, גם אם הם חפצים בשידרוג הבית, אין בכך להוות הצדק לפגיעה בזכויות קנין של בעלי דירות בבית, ללא הסכמתם ואף תוך התעלמות מעמדתם.

אין בידי גם לקבל את טענת המניעות או ההשתק שמעלים הנתבעים בסיכומיהם.

התובעים פעלו כפי שמצופה ממי שמתנגד לבניה של שכנו בבית משותף. סביר בעיני כי בעלי דירה לא "ירוצו" לבית המשפט לקבלת סעדים בטרם ישנה מוחשות כלשהי לבניה המבוקשת, ובהקשר זה, סביר כי בעלי הדירות ימצו תחילה את ההליכים התכנוניים, לרבות הגשת ערר, ורק אם ההליכים התכנוניים לא יביאו לתוצאה הרצויה מבחינתם יפנו לערכאות משפטיות. ויודגש, ממילא בחינה שלמה ומלאה של כל ההיבטים הקנייניים תוכל להעשות רק כאשר ישנו היתר בניה מאושר ממנו ניתן ללמוד מהי הבניה המתוכננת.

אין גם לקבל את טענת השיהוי בנסיבות בהן מבקשים הנתבעים לבנות ברכוש המשותף בבית כאשר הם מודעים להתנגדות חלק מבעלי הדירות לבניה המתוכננת וכאשר אין בידם הסכמות נדרשות על פי דין לביצוע הבניה. לכל זאת יש להוסיף גם את חוסר תום ליבם של הנתבעים בהליך דנן, כפי שפורט לעיל. בהקשר זה נכון יהיה גם להפנות לאשר פסקתי במסגרת ההחלטה בבקשה לסעד זמני בתיק זה מיום 21.05.12.

בכל הקשור לטענה בדבר "השתלטות" על החצר המשותפת הרי שלא עלה בידי התובעים להוכיח כי החצר האחורית גודרה על ידי הנתבעים - התמונות שצורפו (מוצג ת/1 ו- ת/2 ונספח ה' לכתב התביעה) אינן מלמדות על גידור כלשהו של החצר האחורית. אומנם, מתמונות אלו ניכר כי ישנה גישה ישירה מדירות הנתבעים לחצר האחורית. אולם, אין בכך די כדי ללמד על הפיכת הגינה האחורית לגינה פרטית תוך חסימת הגישה מבעלי הדירות האחרים. בהקשר זה ניכר מן התמונות כי הגינה האחורית איננה מגודרת בחלק המצוי מול דירת הנתבעים 1 וחלק הגינה המצוי מול דירת הנתבעים 2. יש גם בכך ללמד כי אין המדובר בגינות אשר יוחסו באופן פרטני לכל אחת מהדירות בקומת הקרקע.

בהקשר זה הנטל להוכיח הטענה מוטל על התובעים. אולם, למעט עדותם בהקשר זה, לא הובאה כל ראיה אחרת מטעמם בדבר חסימת הגישה לגינה, אפילו לא תמונה. מאידך העידה הגב' ישראל כי "כל הדיירים יכולים להיות שם לא תפסתי חזקה במקום אין לי התנגדות שיעשו כל שימוש" (עמוד 12 שורה 18). כך העיד גם מר טרצינר "המעבר חופשי אצלנו בחצר ולא היה שום דבר סגור אין שום עניין לעבור הכול פתוח אפשר להשתמש וגם משתמשים הקומה הכי עליונה" (עמוד 14 שורות 23-24). עדותם זו לא נסתרה כאמור.

ויודגש, אין מחלוקת כי החצר האחורית וכל הגינה בבית הינם רכוש משותף אשר השימוש בו מותר ואפשרי לכל אחד מבעלי הדירות בבית, גם על פי עדותם הנ"ל של הנתבעים. בהקשר זה, אף אם נכונה טענת הגב' ולטר כי נשתלה צמחיה שאיננה מאפשרת מעבר (עמוד 6 שורות 26-29), הרי שבסמכות האסיפה הכללית להחליט על הסרת צמחיה זו, גיזומה וכיוצ"ב. כך גם נכון הדבר בנוגע לדשא הסינטטי המותקן בגינה האחורית או משטח הלבד שליד דירת הנתבעים 2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 186/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, כל עוד לא התקבלו החלטות של האסיפה הכללית בהקשרים אלו, משלא הוכח כי הנתבעים חסמו את הגישה לגינה האחורית ומשהובהר והוצהר על ידי הנתבעים כי הגינה האחורית הינה רכוש משותף החופשי לגישה ושימוש לכל בעלי הדירות בבית, אין מקום ליתן הסעד המבוקש בכתב התביעה בהקשר זה. ממילא התובעים גם זנחו את הסעד המבוקש בהקשר זה בסיכומים מטעמם.

לפני סיום אעיר כי צודקים הנתבעים בדבר הרחבת החזית האסורה בסיכומי התובעים 2 ובעיקר שימוש בטיעונים עובדתיים שלא הוכחו, ולו בבדל של ראיה. לפיכך, התעלמתי בפסק הדין מטענות אלו של התובעים 2.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ונותן בזה צו האוסר על הנתבעים לבצע כל עבודת בניה להרחבת דירתם, לרבות עבודות לבניית ממ"ד, ללא קבלת הסכמת הרוב הנדרש בהתאם להוראות חוק המקרקעין או חוק החיזוק בהתאמה (ככל שזה יחול).

כמו כן אני מחייב את הנתבעים להרוס את אשר בנו ברכוש המשותף בבית ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

על הנתבעים לבצע את האמור לעיל בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

בנוסף לאמור לעיל ישלמו הנתבעים (ביחד ולחוד) לתובעים 1 סך של 10,000 ₪ ולתובעים 2 סך של 4,000 ₪, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (כולל עבור החזר אגרת תביעה ושכ"ט עו"ד), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שנערכו 2 דיונים בתובענה, הוגשו סיכומים בכתב וכן נוהל הליך למתן סעד זמני שנקבע בו כי הוצאותיו יפסקו במסגרת ההליך העיקרי.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ג שבט תשע"ג, 24 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב